

1503405-05.2021.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... caso contrário, seria incriminado por tráfico. Os policiais militares também o subjugaram, dizendo que o prenderiam por tráfico caso fosse solto. Não conhecia os policiais, pois residia em Pederneiras e viera a Jaú para tirar documentos e acabou tendo uma recaída em seu vício.

Os policiais militares Marcelo e Gilmar relataram, em síntese, que estavam em patrulhamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503405-05.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2255624/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20344614 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5342/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2255624 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2255624 - 01º D.P. JAÚ, 5342/21/406 - 01º D.P. JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA e EDIBERTO APARECIDO DE CAMPOS estão sendo processados como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 29, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2021 (fls. 265/267).

Citados (fls. 276/277), os réus apresentaram defesa (fls. 306/308).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados (fls.

397/398).

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação dos réus e a defesa requereu a absolvição deles ou, se o caso, o afastamento da qualificadora de escalada.

É o relatório.
DECIDO.

Cumprе consignar que, a despeito do artigo indicado na denúncia, ela descreve a qualificadora da escalada e o concurso de agente, o que torna desnecessário o aditamento.

A ação é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/13), boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18), autos de reconhecimento (fls. 25/26), auto de avaliação (fls. 27), fotografias (fls. 33/36, 57/58 e 83), laudo pericial (fls. 281/286) e pela prova oral.

Interrogado em juízo, os réus negaram os fatos.

Luiz Fernando aduziu que encontrou o saco com fios de cobre em uma caçamba enquanto estava pegando produtos recicláveis com o corréu. Em seguida, foram abordados pelos policiais militares, que o agrediram e afirmaram que, caso não assumisse o furto, “forjariam” um delito de tráfico. Por esse motivo, confessou à autoridade policial a perpetração do delito.

Ediberto confirmou o relato do corréu quanto ao encontro dos fios, enquanto catavam recicláveis. Aduziu que não conhecia o corréu antes dos fatos e o encontrou na rua naquele dia. Sustentou que sofreu torturas físicas e psicológicas do delegado para assumir a prática do furto, sob a ameaça de que, caso contrário, seria incriminado por tráfico. Os policiais militares também o subjugaram, dizendo que o prenderiam por tráfico caso fosse solto. Não conhecia os policiais, pois residia em Pederneiras e viera a Jaú para tirar documentos e acabou tendo uma recaída em seu vício.

Os policiais militares Marcelo e Gilmar relataram, em síntese, que estavam em patrulhamento durante a madrugada quando avistaram os réus na via pública carregando um grande saco nas mãos. Realizaram a abordagem e verificaram que no interior do saco havia significativa quantidade de fios de cobre e algumas ferramentas. Na época havia alto índice de furtos de fio de cobre em Jaú e, questionados, os acusados disseram inicialmente que tinham encontrado o objeto em uma caçamba. Ao serem inquiridos separadamente, eles confessaram a subtração dos fios e indicaram a casa onde o crime foi cometido. O PM Marcelo foi ao lugar apontado pelos acusados e encontrou um imóvel destelhado. Os acusados detalharam que Luiz Fernando foi o responsável por subir no telhado e extrair os fios, enquanto Ediberto vigiava o perímetro. O proprietário do imóvel não foi encontrado e vizinhos contaram que ele estava concretizando reformas para futuro aluguel ou alienação.

Pois bem.

Inicialmente, observo que que não merece amparo as alegações defensivas atinentes à inexistência de materialidade do delito, em virtude da não identificação da vítima. Não obstante o proprietário do imóvel não tenha sido encontrado e qualificado, restou demonstrado pelo conjunto probatório que os fios foram furtados de casa que, segundo informações prestadas por vizinhos, possuía dono e que estava sendo reformada para ser vendida ou alugada. Portanto, é certo que a res integrava patrimônio alheio e, assim, seu apoderamento pelos acusados configura conduta

ilícita.

A autoria é certa.

Os réus confessaram o furto em seus interrogatórios perante a autoridade policial (fls. 12/13), mas alteraram suas versões em juízo e afirmaram, em suma, terem sido coagidos a assumir a autoria.

Suas negativas, todavia, foram infirmadas pelas provas produzidas.

Cumpra desde logo observar que os réus não apontaram motivo que justificasse a falsa incriminação por parte dos agentes da lei. E, contradizendo suas assertivas, as fotografias de fls. 84/97 revelam que eles não apresentam nenhuma lesão visível, fato corroborado pelos laudos de fls. 159/160.

Nesse contexto, não há como acolher a tese defensiva de falsa incriminação, até porque, se assim fosse, haveria que se reconhecer um verdadeiro conluio entre policiais militares, delegado e perito para imputar aos réus falsamente um crime de furto, o que não é minimamente crível.

De outro lado, as narrativas dos policiais se mostraram coerentes e harmônicas com as demais provas e com as confissões extrajudiciais, em consonância com os autos de reconhecimento do imóvel (fls. 25/26) e fotografias de fls. 33/36, 57/58 e 83.

Os réus foram surpreendidos na posse da res furtiva, o que, de resto, faz presumir a autoria da subtração, não afastada por qualquer prova.

A esse respeito, veja-se:

“Em se tratando de crime de furto, a apreensão da res furtiva em poder de pessoa sobre quem recaem suspeitas de autoria, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sem a qual a presunção se transmuda em certeza, autorizando o desate condenatório” (TACRIM-SP- Ac- Rel.Passos de Freitas- RJD 24/330).

“A apreensão, ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em relação a autoria” (TACRIM-SP -Ac- Rel. Fernandes de Oliveira- RJD 27/180).

Ao contrário do sustentado pelos acusados, eles não tinham em seu poder objetos a serem reciclados, mas ferramentas (fls. 281/286) aptas à extração dos fios, o que corrobora o animus furandi.

O crime restou consumado, pois, além de ter havido a inversão da posse, ela foi, inclusive, mansa e pacífica até a abordagem policial.

O delito foi praticado durante a madrugada, evidenciando-se a majorante prevista no § 1º, do artigo 155, CP.

As qualificadoras de escalada e concurso de agentes foram comprovadas pela prova oral, pelas fotografias de fls. 33/36, que explicitam o acesso pelo telhado, e pelo laudo pericial de fls. 386/394.

Assim, não merecem guarida as teses defensivas e a condenação é medida de rigor.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, presentes duas qualificadoras, uma delas qualifica o crime e a outra deverá ser computada como circunstância judicial. Deste modo, fixo a pena-

base acima do mínimo legal em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as agravantes da reincidência (Luiz Fernando - fls. 355/364 - Processos nº 1500533-11.2019.8.26.0165, 0001939-93.2009.8.26.0165, 0002389-36.2009.8.26.0165; Ediberto - fls. 328/335 - Processos nº 0000058-65.2010.8.26.0062, 0000679-28.2011.8.26.0062, 0001013-96.2010.8.26.0062, 0001305-81.2010.8.26.0062, 0000659-63.2018.8.26.0071) e a prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos").

Por conseguinte, e, considerando que as reincidências são múltiplas e que todas as condenações dos acusados são decorrentes de crimes contra o patrimônio, aumento as reprimendas de ½ para 3 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 155, § 1º, CP, tendo em vista que o delito foi praticado durante o repouso noturno. Nesse ponto, trago à baila entendimento jurisprudencial pela possibilidade da aplicação de mencionada causa de aumento ao furto qualificado:

"RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I - As normas que estabelecem as qualificadoras do furto e a causa de aumento do repouso noturno são harmonizáveis, haja vista que o legislador tanto nas qualificadoras objetivas (§ 4º do art 155) como na referida causa de aumento apreciou e revalorou o desvalor da ação do agente, e não fez uma análise sob a ótica do desvalor do resultado. II - Numa graduação do injusto, é mais reprovável o delito de furto cometido, como in casu, mediante escalada e durante o repouso noturno (ocasião em que o bem jurídico tutelado tem menor vigilância por parte do dono ou possuidor) do que cometido no período diurno. Desta forma, em uma análise em concreto acerca da compatibilidade dos institutos, a norma estabelecida no § 4º e a do § 1º do art. 155 do CP são compatíveis entre si. Precedentes. Recurso especial provido para reconhecer a incidência da causa de aumento do repouso noturno no crime de furto qualificado". (STJ - T5 - REsp 1624292/SC - Rel. Ministro Felix Fischer, julg. 18/04/2017). "Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente

compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada." (STF - 2ªT - HC 130952/MG - Rel. Ministro Dias Toffoli, julg. 13/12/2016).

Assim, aumento as penas dos acusados de 1/3, perfazendo 4 anos e 8 meses de reclusão e 21 dias-multa, que se tornam definitiva em razão da ausência de outras circunstâncias modificadoras.

O valor do dia multa será fixado no mínimo legal, ante a ausência de elementos identificadores de condição financeira privilegiada pelos acusados.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado para ambos, considerando as penas fixadas e a reincidência.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

"O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão"

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, “caput”, da CF)”(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR os réus LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA e EDIBERTO APARECIDO DE CAMPOS à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime descrito no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Os réus não poderão apelar em liberdade, pois permaneceram presos no curso do processo e remanescem os requisitos que ensejaram sua custódia cautelar, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. Recomendem-se, pois, na prisão em que se encontram.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA